

第 59 問

A 社は、取引先である B 社に融資をしていたが、近年、B 社の資金繰りが悪化してきたため、融資を打ち切るかどうかの判断に迫られることになった。A 社の代表取締役である甲は、B 社との取引を担当しており、B 社の代表取締役である乙と個人的な付き合いもあったことから、融資を打ち切るのには慎重な態度を示していた。ある日、甲は、乙とともに趣味であるゴルフをしていたところ、乙から、「甲さん、B 社への融資を打ち切ることは止めてください。ちょうど今、新商品が完成したばかりなんです。ここで、追加融資を受けることができれば、新しい生産ラインを導入して、一斉に新商品を販売することができます。ヒットすれば、今までの分も含めて、返済させていただきますから。」などと頼みこまれた。この際、乙は、新商品が必ずヒットするようなものではないと思っていたが、うまくいけば A 社に対する借金を全て返済できる可能性もあると考えていた。甲は、新商品の存在を知っており、市場の動向から客観的に判断すると、おそらくヒットすることはないだろうと考えていたが、乙の懇願を断りにくかったこと、B 社が倒産し、今までの融資分を回収できなくなったら自分の責任問題となり得ること、万が一新商品がヒットしたら確かに今までの融資を含めて貸金を回収できるようになることなどから、B 社に 1 億円を無担保で貸し付けた。

その後、B 社は新しい生産ラインを導入して新商品を製造したが、大きな利益を産むことができなかったため、倒産し、A 社は融資金を回収することができなかった。

甲及び乙の罪責について、論じなさい（特別法違反の点を除く。）。

第1 甲の罪責

1 甲がA社を代表して、B社に1億円を無担保で貸し付けた行為につき、背任罪(247)を検討することになる。

2(1) まず、図利加害目的であるが、判例(最決平10.11.25【百選Ⅱ73】)が採用する消極的動機説による限り、本問のように、本人(A社)の利益を図る目的と、自己(甲)・第三者(B社)の利益を図る目的が混在している場合、積極的に本人の利益を図ったと認められれば、図利加害目的が否定されるが、本問では、そのような事情はないため、これを肯定することになる(【論点】図利加害目的 ④ 旧H8-2H18-2)。

総合 252 頁 論証 126 頁

(2) そして、「任務に背く」であるが、市場の動向から客観的に判断するとおそらくヒットすることはないだろうと考えていたにもかかわらず、独断で、1億円もの大金を無担保で貸し付けているのであるから、これも認められる(【論点】背任罪の本質(「任務に背く」(247)の意義))。

総合 252 頁 論証 126 頁

(3) また、「財産上の損害」について、判例(最決昭58.5.24【百選Ⅱ72】)は、「『本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ』とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいうと解すべきである」としている。

資金繰りが悪化した会社に対する無担保の貸付けは、経済的見地からみて、債権の実価を下回ると考えられるから、「財産上の損害」も認められる(【論点】「財産上の損害」(247)の意義)。

総合 253 頁 論証 126 頁

3 以上より、甲には背任罪が成立する。

※ このような財務状態が悪化した不良先への貸付けの事案は実務上(特別)背任罪として処理されている。もっとも、「横領」概念の理解や横領罪と背任罪の区別基準次第では、横領罪が成立する可能性も十分あるとの指摘がなされている。このような観点からは、本問において、横領罪の成立を検討することも可能だろう。

第2 乙の罪責

1 乙には、背任罪の共同正犯(60)の成否が問題となる(【論点】背任罪の共犯(共同正犯))。

総合 255 頁 論証 128 頁

2(1) 乙は甲に対して融資の働き掛けをしているが、経済取引界において融資等を得るために働き掛けを行うことは通常の経済活動といえる範囲ならば許容されるべきであるため、背任罪の共犯の成立において、成立範囲を一定の限度に制限するべきであると解されている。

もっとも、その理論構成については、背任罪プロパーの問題とする見解、共犯論の問題とする見解、後者の中で、広義の共犯一般の成立要件の問題とする見解、正犯性の問題とする見解などに分かれており、判例の立場も明らかではない(最決平15.2.18【百選Ⅱ74】、最決平17.10.7、最決平20.5.19参照)。

(2) 本問では、乙には、特に強引で執拗な融資の申し出をしているわけではないし、うまくいけばA社に対する借金を全て返済できる可能性

があると考えていたことからすれば、共同正犯の成立は否定されるべきであろう。

なお、この問題の理論的な位置づけをどのように解するのかにもよるが、通常のエconomic活動といえる範囲内においては、狭義の共犯すら成立しないと解すべきだろう。

答案構成

第1 甲の罪責

1 背任罪（247）の成否

↓

2 「他人のためにその事務を処理する者」

↓

あてはめ

↓

図利加害目的

↓

消極的動機説

↓

あてはめ

↓

「任務に背く」

↓

あてはめ

↓

「財産上の損害」

↓

経済的見地において判断する

↓

あてはめ

↓

故意（38 I）

↓

3 甲に背任罪が成立する

第2 乙の罪責

1 背任罪の共同正犯（60）の成否

↓

働き掛けの程度が経済取引における社会通念に照らして、明らかに逸脱しているか

↓

あてはめ

↓

2 乙は不可罰である

第1 甲の罪責

1 甲がA社を代表して、B社に1億円を無担保で貸し付けた行為につき、背任罪（247条）が成立しないか。

2 背任罪の成立には、①「他人のためにその事務を処理する者」であること、②「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」（図利加害目的）、③「任務に背く行為」、④「財産上の損害」が必要である。

(1) 甲はA社の代表取締役であるから、①A社との任用契約に基づいて（会社法330条、民法643条）、A社という「他人のためにその事務を処理する者」であることは明らかである。

(2) ②図利加害目的の要件は、本人図利目的を除くことを裏側から規定したものである。そうだとすれば、本人の利益を図る目的でした行為は処罰できない。

そこで、本人の利益を図る目的と、自己・第三者の利益を図る目的が混在している場合、積極的に本人の利益を図ったと認められれば、図利加害目的が否定される。

本件では、万が一新商品がヒットしたら確かに今までの融資を含めて資金を回収できるようになるとは考えているものの、乙と個人的な付き合いがあったことにより乙の懇願を断りにくかったこと、また、B社が倒産し、今までの融資分を回収できなくなったら自分の責任問題となり得ると考えたことが融資に大きく影響しており、積極的に本人であるA社の利益を図ったとは認められない。

1

したがって、②図利加害目的は認められる。

(3) ③「任務に背く」とは、法律上の事務、事実上の事務を問わず誠実義務に反する財産侵害行為のことを指すと解すべきところ、資金繰りが悪化したB社に1億円もの大金を無担保で貸し付ける行為は、代表取締役としての誠実義務に反するものであるといえる。

したがって、③「任務に背く行為」も認められる。

(4) ④「財産上の損害」は、行為者に事務処理権限が与えられていることに鑑み、全体財産において判断すべきである。ただし、現実の取引社会では、額面は同じでも債権と現金の価値は全く異なるし、担保の有無等でも債権の価値は大きく異なるから、その判断は、経済的見地について考えるべきである。

本問では、A社は、資金繰りが悪化したB社に無担保で貸付けを行っているから、債権の実価は1億円を下回るのが通常である。

したがって、経済的損害は発生しているといえ、④「財産上の損害」も認められる。

(5) 甲には上記各事実についての認識に欠けるところもないから、故意も認められる（38条1項）。

3 以上より、甲には背任罪が成立する。

第2 乙の罪責

1 (1) 乙は甲に対して当該融資の働き掛けをしており、甲と意を通じて上記融資を引き出していることから、甲と「共同して犯罪を実行した」ものとして、背任罪の共同正犯（60条）となることが考えられる。

2

もっとも、経済取引界において融資等を得るために働き掛けを行うことは通常の経済活動といえる範囲ならば許容されるべきである。安易に背任罪の共犯を成立させれば、自由な経済活動を過大に制約することとなるためである。

そこで、背任罪の共犯の成立において、成立範囲を一定の限度に制限する必要がある。

上記のとおり、安易に取引相手に共同正犯の成立を認めると、自由な経済活動を過大に制約することになることを考慮に入れば、その働き掛けの程度が経済取引における社会通念に照らして、明らかに逸脱しているかを基準として判断すべきである。具体的には、当該客観的事実を基礎にしつつ、行為者の主観的事実をも補充的に考慮しながら総合的に判断する。

(2) 乙は、新商品が必ずヒットするようなものではないと考えているものの、うまくいけばA社に対する借金を全て返済できる可能性があるとも考えており、融資が返済できなくなることについて、確定的認識があったわけではない。

また、特に強引で執拗な融資の申し出をしているわけではないし、甲との個人的な人間関係を殊更利用しているわけでもない。

さらに、A社がB社に対して、融資に応じざるを得ないような事情も認められない。

これらの事情を総合的に考慮すれば、乙の融資にかかる働き掛けの程度が社会通念に照らして明らかに逸脱しているとはいえない。

3

2 以上から、乙には背任罪の共同正犯は成立しないから、乙は不可罰である。

以 上

4